

JUZGADO CIV.COM.CONC.FAM. 2a NOM - SEC 4 - ALTA GRACIA

Protocolo de Autos N° Resolución: 53

Año: 2024 Tomo: 1 Folio: 118-132

EXPEDIENTE SAC: xxx - L., L. R. Y OTROS - AUTORIZACIONES
PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 53 DEL 14/03/2024

AUTO NUMERO: 53.

ALTA GRACIA, 14/03/2024. **Y VISTOS:** Estos autos caratulados "**L. L. R. Y OTROS - AUTORIZACIONES - Expte N° xxx, iniciados con fecha 05/12/2023**", de los que resulta que con fecha 05/12/2023 comparecen los Sres. D. E. P. DNI xxx, S. M. S. DNI xxx y L. R. L. DNI xxx; con la asistencia letrada de la Ab. Romina Vittar, solicitando se preste autorización judicial para la determinación preventiva de filiación en los términos del art. 581; 562 y concordantes del CCCN. Relatan que S. M. S. y D. E. P. comenzaron una relación afectiva hace aproximadamente trece años. En el año 2013 contrajeron matrimonio hicieron su vivienda - a través de un plan PROCREAR en el terreno de la madre de D. en Colonia Caroya y comenzaron a soñar con agrandar la familia. Al poco tiempo los problemas de salud que ya traía S. (Síncope vasovagal cardio inhibitor) se profundizaron y aparecieron otros (diabetes), por lo que los médicos le recomendaron que no quedara embarazada. Buscaron información en internet, e hicieron una consulta en el centro de fertilización Asistida "F.". Comprendieron que debían encontrar una persona que esté dispuesta a llevar el embarazo por ellos y comenzaron la búsqueda de quien pudiera ayudarlos. Lo comentaron en su círculo íntimo, pero nadie estaba en condiciones de asistirlos. Casi sin esperanzas D. encontró en un grupo de la red social "Facebook" personas que compartían su experiencia en ser padres a través de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, así fue como conocieron a L. quien les contó que estaba en pareja con M. y que habían sido madres por inseminación casera puesto que (años atrás) las TRHA no eran una fuente de filiación reconocida en el Código Civil. A partir de ese contacto las familias de D., S., L. y M. comenzaron a acercarse. Detallan que L. L. tiene 37 años y está en pareja hace 15 años con M. M. G. de 48 años, juntas ahíjan a L. de 13 años y L. de 7, son oriundas de Buenos Aires pero decidieron criar a sus hijos en Villa del Prado buscando la tranquilidad que ofrece el paraje. L. y M. M. vivieron en carne propia la imposibilidad de tener descendencia propia y tienen la convicción de

que es preciso ser solidarios con quien lo necesita, por lo que decidieron acompañar a D. y S. en su sueño de ser padres. Así fue cómo, luego de levantado el ASPO, comenzaron con un largo proceso con el objeto de que L. gestara el niño/a de D. y S.. Refieren que como primera medida el Instituto de fertilidad sugirió una serie de estudios tales como, análisis de sangre que incluyera lo siguiente: 1. Hemograma y coagulograma 2. Perfil metabólico (glucemia, hepatograma con lipidograma) 3. Función renal (urea y creatinina) 4. Perfil hormonal (PRL, TSH, T4l, T3) 5. Grupo y factor 6. Hepatitis B s Ag (Antígeno de Superficie) 7. Hepatitis B core IgM 8. Hepatitis C anticuerpo 9. VDRL 10. VIH anticuerpo I y II 11. Toxoplasmosis 13. Chagas 14. Rubeola, examen físico ginecológico, ecografía ginecológica y mamaria, cultivo de flujo, urocultivo, citología cervical entre otros, con el objeto de constatar el estado de salud de L.. Habiendo resultado todos dentro de los parámetros normales el profesional tratante llegó a la conclusión de que se encontraba en perfecto estado físico para realizar el procedimiento. Asimismo, se indicó evaluación psicológica de todos los participantes; además, se les informó que el tratamiento pretendido era viable pero, ante la falta de legislación al respecto y para evitar problemas legales, debían solicitar ante la justicia autorización para que el niño o niña nacida fuera inscripto/a como hijo/a de la pareja compuesta por S. y D. (progenitores con voluntad procreacional). Acto seguido se suscribieron los consentimientos informados donde cada uno de los participantes de la práctica expresan su voluntad. Así S. y D. indican que son los progenitores intencionales y L. expresa su voluntad contraria a ser considerada progenitora, M. M. acompaña la decisión de L. Finalizan su relato mencionando que el día 12 de julio del corriente año se decidieron a realizar la transferencia del embrión compuesto por material genético de D. y ovodonación (anónima) al vientre de L. Destacan que los gastos son cubiertos en su totalidad por la pareja comitente y que L. cuenta con un plan de salud premium para afrontar todas las vicisitudes del estado de gravidez.

Solicitan se ordene que la niña/o nacida/o de la técnica de reproducción médicamente asistida llamada gestación por sustitución, con material genético de uno de los comitentes y ovodonación sea inscripta inmediatamente al momento de nacer como hija/o de S.M.S. y D. E. P. por ser quienes poseen la voluntad procreacional y no de la gestante L. R. L. quien expresa su voluntad contraria a ser considerada progenitora y no la une vínculo genético alguno con la niña. Definen la gestación por sustitución, mencionando que es un procedimiento reconocido por la OMS. Expresan que no hay ninguna norma en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos que inhiba la gestación por sustitución, pero que la misma encuentra su base en la CADH al referirse a los derechos a la vida privada y familiar (Art. 11) a la integridad personal (Art. 5.1) a la libertad personal (Art. 7.1) a la igualdad y a no ser discriminado (Art. 24) como en cuanto al derecho a

procrear y conformar una familia (Art. 17) en cumplimiento del antecedente Artavia Murillo del año 2016.

Resaltan que si bien el Art. 562 del CCCN ordena que la filiación por técnicas de reproducción, determina que la filiación corresponde a la persona que dio a luz. Esta regulación no se aplicaría en forma textual a los casos de gestación por sustitución porque no reconoce la voluntad de la persona gestante, por lo que entienden que sería inconstitucional o al menos no aplicable para el caso de gestación por sustitución, toda vez que no respeta el derecho a la identidad de la niña que está siendo gestada, ni a la autonomía de la voluntad de la gestante, ni al proyecto de vida de la pareja. Luego hacen un análisis del Anteproyecto de reforma del CCCN, en donde se había contemplado la gestación por sustitución, enumerando algunas condiciones para la procedencia de la homologación por parte del juez aclarando, que si bien el mismo no se encuentra vigente, se propone que los requisitos pensados por la comisión redactora, sean considerados a la hora de brindar mayores argumentos que sostengan la necesidad de que su señoría ordene la inscripción de la niña como se pide. Los peticionantes, formulan compromiso a informarle a la menor cómo fue concebida y gestada, en respeto al derecho a la identidad y a conocer sus orígenes. También luego del nacimiento, a realizar un examen de ADN a fin de comparar su relación genética con el menor, para ser puesto en conocimiento del Tribunal. Ponen en conocimiento del Tribunal que L. cuenta con cobertura de salud integral y que los padres intencionales asumirán todos los costos que pudieran surgir durante el embarazo y el parto. Ofrecen prueba documental, informativa, testimonial y pericial, asimismo hacen reserva del caso federal. Con fecha 12/12/2023 se admite la solicitud y se emplaza a acompañar la documental consistente en los consentimientos informados de los Sres. P.; S. y L- cumplimentado con fecha 13/12/2023-; en la misma fecha se libra oficio al Equipo técnico multidisciplinario, encomendando valoración interdisciplinaria respecto de la gestante por sustitución Sra. L. R. L. en su domicilio y su grupo familiar, quien refieren se encuentra cursando un embarazo de 22 semanas, y de la pareja comitente Sres. S. M. S. y D. E. P., adjuntando dicho informe con fecha 08/02/2024.

El día 13/12/2023 toma intervención el Sr. Fiscal de Instrucción del Primer Turno y con fecha 18/12/2023 tomar intervención la Sra. Asesora letrada Dra. CINTIA SOLEDAD CENA, Defensora de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Alta Gracia y Río Tercero en la presente causa en el carácter de Representante Complementaria del niño/niña por nacer, en los términos del art. 103 inc. "a" del Código Civil y Comercial de la Nación y del art. 67 inc. "a" de la ley 9944. Seguidamente se fija audiencia a fin de tomar contacto personal con las partes de autos.

Con fecha 19/12/2023 se hace saber a las partes que se ha fijado fecha a los fines de la entrevista con el Equipo Técnico Multidisciplinario de la sede, el día 06/02/2024 con L. L. y el día 07/02/2024 con los Sres. S. y P.

El 28/02/2024 se celebra la audiencia designada a fin de tomar contacto con las partes involucradas, a la que comparecen las partes Sres. D. E. P. DNI xxx, S. M. S. DNI xxx con el patrocinio de la Dra. Vittar Romina; L. R. L. DNI xxx con la asistencia de la Auxiliar colaboradora de la Sra. Asesora letrada (Dra. Graciela Gamboa), Dra. Eugenia Pittar y con la presencia de la Auxiliar Colaboradora de la Sra. Asesora Letrada (Dra. Cintia Cena), Dra. Emma Corinaldesi. Seguidamente se tienen presentes los consentimientos prestados por los comparecientes. Se corre vista de todo lo actuado a la Sra. Asesora Letrada, Defensora de Niñez, Adolescencia, VF y de Género de Alta Gracia, evacuando la misma la Dra. M. Alejandra Assadourian PLT, con fecha 04/03/2024. Corrida la vista al Sr. Fiscal de Instrucción del Primer Turno Dr. Diego Martín Fernández, respecto de la inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN, la evacúa con fecha 08/03/2024. Dictado el decreto de autos (08/03/2024), queda la causa en condiciones de ser resuelta.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Plataforma fáctica: Los presentes autos llegan a despacho a fin de resolver el pedido de autorización judicial para la determinación preventiva de filiación en los términos del CCCN, solicitud incoada por L. R. L. DNI xxx (gestante); la Sres. D. E. P. DNI xxx, S. M.S. DNI xxx con el objeto de que se inscriba al nacido/a como hijo/a de la pareja comitente, atento ser titulares de la voluntad procreacional.

SEGUNDO: Marco teórico: Como cuestión liminar es preciso resaltar que conforme lo dispone el **Art. 558 del CCCN** *"la filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. (...)".* Recepta la norma fondal, la filiación de niños que nacen por el uso de las TRHA - entendidas como "los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo- (ley 26.862). En general las TRHA se clasifican primeramente según la mayor o menor complejidad de la técnica; en este sentido, se observan técnicas de baja (inseminación) y alta complejidad (in vitro e ICSI). Luego, existe otra clasificación según se utilice material genético de la propia pareja o de un tercero -donante, que puede ser anónimo o conocido-, es decir, fertilización homóloga en el primer supuesto o heteróloga, en el segundo caso. Por otra parte, y fuera de estas clasificaciones, cabe tener en cuenta un especial procedimiento de TRHA como lo es la denominada "gestación por sustitución", que se presenta, cuando en el proceso reproductivo interviene una tercera persona (mujer) a los fines de gestar un niño para otra persona o personas (pareja) que son quienes quieren ser padres. La gestación por sustitución, implica un acuerdo de voluntades en el que una o dos personas aportan material

genético propio o de terceros (comitentes) y una mujer que llevará adelante un embarazo (gestante), utilizando para ese proceso una de las denominadas "Técnicas de Reproducción Humana Asistida". De manera indudable este tipo de procreación importa una visión diferente a las clásicas maternidades o paternidades, que nos lleva a replantearnos muchos de nuestros tradicionales y estereotipados posicionamientos sobre la cuestión. En este sentido ya en el año 2011 Eleonora Lamm advertía que "inevitablemente, las TRA desafían cambios en la normativa vigente debido a que amplían las opciones de reproducción y cuestionan las nociones tradicionales de paternidad, maternidad, embarazo, así como también la del parto" (Cfr.: Lamm, Eleonora: "La autonomía de la voluntad y aplicabilidad en las nuevas formas de reproducción. La maternidad subrogada. La importancia de la voluntad como criterio decisivo de la filiación y la necesidad de regulación legal"; Revista Interdisciplinaria de Derecho de Familia, N° 50, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 108).

Ahora bien, la "gestación por sustitución" no fue incluida expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación al regular la filiación en general, ni en relación a las técnicas de reproducción asistida en particular. Tampoco está concretamente incluida en la Ley N° 26.862 (Ley de "Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida"). Sin embargo, debo recalcar que tampoco existe norma alguna que la prohíba expresamente lo que conlleva -como señala la doctrina calificada - a una situación de "alegalidad". Este término acuñado por doctrinarias y juristas argentinas como Mariana de Lorenzi nos lleva con exactitud a la situación en que se encuentra la figura en tanto el legislador no la ha regulado, pero tampoco la ha prohibido. Por ello, quienes solicitan la autorización apelan al art. 19 de la Constitución Nacional (en adelante CN) afirmando su viabilidad, en tanto todo lo que no está expresamente prohibido se encuentra permitido. Dicha previsión constitucional es acompañada del resto del ordenamiento nacional y supranacional el que enmarca y forma parte del engranaje de derechos fundamentales y doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22; caso Artavia Murillo vs. Costa Rica). Por lo tanto, la autorización que se peticiona engasta en una figura que si bien no se encuentra regulada responde a derechos fundamentales como lo son el derecho a formar una familia (Conf. artículo 17 Convención Americana sobre Derechos Humanos), el derecho a acceder a los beneficios de la ciencia (artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y art 27 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y en definitiva alcanzar un estándar de vida o calidad de vida de la cual todas las personas somos merecedoras (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). En este esquema, es oportuno referir a los presupuestos y normativa que incluye a la **gestación por sustitución en el anteproyecto del CCCN**, el que a la postre, si bien no conforma parte de nuestro

ordenamiento jurídico, ha delineado las pautas seguidas en muchas ocasiones por la jurisprudencia nacional, a los fines de cubrir el vacío legal existente en los supuestos de sustitución de vientre. En este sentido, el art. 562 establecía: *"el consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Código y la ley especial. La filiación quedará establecida entre el niño nacido y los comitentes mediante prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial. El juez puede homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que: a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer, b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus gametos; f) la gestante no ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de dos veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, un hijo propio..."*. En este orden, el órgano jurisdiccional debe responder ante un planteo que ponga en escena la posibilidad de concretar este proyecto de vida que conlleve un paso hacia este derecho fundamental (formar una familia, acceder a la posibilidad de procrear a través de una TRHA). Sin embargo, como cualquier derecho no es absoluto, y existen circunstancias o condiciones que necesariamente deben cumplirse a fin de que este procedimiento pueda ser legítimo y autorizada. Uno de los estándares de mínima que deberá darse es la simetría en la búsqueda de dicho proyecto entre comitentes y gestante; el libre y pleno consentimiento; la evidente exteriorización de la voluntad procreacional; y la elaboración concreta y palpable de dicha práctica. Ello en miras, también, de entender cuál será el alojamiento de hijo/a que podrán hacer los progenitores voluntarios en el profundo entendimiento de las consecuencias que aparejaría una situación abusiva o al menos poco clara. Estos cimientos son fundantes en la identidad del niño o niña que posiblemente nacerá, enmarcado en el derecho a la "verdad" y a poder conocer cuál fue su origen en un marco de humanidad, legitimidad y legalidad. A la par, y conforme los procesos que imperan en el fuero de familia donde se centra la audiencia como acto jurídico y procesal de envergadura, Notrica ha referido en comentario a un fallo de gestación; *"entendemos que dicha audiencia tienen gran importancia desde una doble finalidad, esto es, confrontar las pruebas ofrecidas inicialmente con las manifestaciones de las partes, y muy especialmente controlar que la mujer que decide llevar a cabo la gestación por sustitución haya tomado en plena libertad la decisión de llevar adelante el embarazo para luego entregar a la niña a los comitentes"* (González, Andrea- Mellón, Pablo-Notrica, Federico "la gestación por sustitución como una realidad que no puede ser silenciada", en www.saij.gob.ar; última compulsa 02 de junio de 2023).

TERCERO: Marco fáctico: El supuesto que nos ocupa se enmarca en la denominada maternidad

subrogada o sustitución de vientre, en donde S. M.S. y D. E. P. han prestado el consentimiento previo, informado y libre ante el centro de Salud F. de someterse a las TRHA, manifestando su voluntad procreacional y por otro lado L. R. L. (mujer/gestante), prestando también su consentimiento previo, informado y libre, se comprometió a llevar adelante un embarazo, con material genético conformado con gametos del Sr D. P. y ovo donación anónima, mediante técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad. Así, en virtud de la manifestación expresa de la gestante de no tener voluntad procreacional, sino que reconoce gestar con la intención de que los Sres. P. y S. sean los progenitores de la niña por nacer, comparecen conjuntamente a solicitar que la niña que nazca sea inscripta, como hija de la pareja comitente quedando de esa manera establecida su filiación y sin establecer vínculo con la gestante. Todo de acuerdo a la relación de causa descripta a la que me remito en honor a la brevedad.

Viabilidad de la autorización.

En primer término, debo poner en conocimiento que este pedido de autorización judicial, si bien es una de las vías idóneas por aceptación jurisprudencial en el marco del Anteproyecto del CCCN, la oportunidad en el que se formuló la petición, se presentó riesgosa sobre todo para la niño/a por nacer, atento la premura con la que debe atenderse la cuestión, por el avanzadísimo estado de gravidez de L. Sin perjuicio de ello, se han tomado todos los recaudos necesarios para que se realice el adecuado control judicial a la forma gestacional seleccionada y que en definitiva se proceda al dictado de la presente resolución.

Ante el silencio legal debemos ser los jueces quienes ante cada caso en concreto tenemos que pronunciarnos acerca de la legalidad de la práctica que se realiza y en definitiva determinar la filiación de los hijos/hijas nacidas por esta técnica. Esta circunstancia condena a los nacidos y a sus gestantes, padres, madres y familiares a un vacío jurídico del que sólo pueden ser rescatados por los jueces, hasta tanto no exista una sentencia judicial que las redima, para que las personas involucradas no permanecen en un estado emocional y legal de incertidumbre. En relación al control jurisdiccional requerido, conforme ya se adelantara estamos ante una situación no contemplada ni regulada por ley, estamos ante una práctica que tiene origen hace ya muchos años, pero que aún no tiene acompañamiento legislativo en nuestro país, lo que a la postre ha tenido variadas estrategias procesales y soluciones jurisprudenciales. Lo cierto es que sin perjuicio de que el Anteproyecto del CCCN, no es ley y por ende no tiene vigencia formal, sus pautas son tomadas como guías o principios a seguir para suplir la ausencia legal de una realidad cada vez más reiterada. Es así que se recurre a la justicia a solicitar una homologación o autorización, de conformidad al Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial presentado en Congreso de la Nación en el año 2012- en el TÍTULO V denominado Filiación, en su CAPÍTULO 2 relativo a

Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida cuando preveía en el art 562 *"Gestación por sustitución. (...) El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que: (...) Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial. Si carece de la autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza"*. Es decir, las partes luego de acudir al centro de reproducción - en nuestro caso F.-, se dirigen a la vía judicial para hacer valer sus derechos, solicitando la autorización pertinente de manera previa al nacimiento de la niña, sin perjuicio que reitero lo óptimo hubiese sido que su requerimiento fuese de manera previa a iniciar el tratamiento y no una vez iniciado, toda vez que los tiempos de los procesos pueden no acompañar el tiempo del tratamiento o del embarazo y correr el riesgo de acudir a otras vías procesales (impugnaciones de maternidad, adopción por integración, etc), en perjuicio de los derechos de todos los sujetos interesados.

Con relación al niño/a por nacer, en este proceso, atento que ya existe en el vientre de L. una persona, se han tomado todos los recaudos para su protección. Así se ha dado inmediatamente intervención a la Asesora Letrada Defensora de Niñez, Adolescencia, VF y de Genero de Alta Gracia, se ha procurado acelerar el proceso a tiempos mínimos, para dictar resolución de manera previa a su nacimiento, para que no sea víctima de una encrucijada legal y pueda ver afectado su derecho a nacer y a desarrollarse en una familia con una identidad dentro de la misma. Como bien lo requiere la Dra. Assadourian, esta resolución se dicta priorizando el interés superior de la persona por nacer como principio rector, es por ello que considero que desde este aspecto la inscripción solicitada redundaría en beneficio del niño/a, donde una familia la está esperando y sería óptimo que su partida de nacimiento ya cuente con la registración de sus datos conforme fue esperada desde su concepción en esta familia, sin afectar el medio natural de su crecimiento, desarrollo y bienestar. Por otro costado, tomo como una "obligación" el compromiso asumido por los progenitores con voluntad procreacional, la de respetar el derecho a la identidad y a conocer sus orígenes de este niño/a, pues ello, les es impuesto por el Art. 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos de Niño y la ley 26.061. A este mismo efecto y bajo los mismos fundamentos legales F. deberán mantener reservada toda la documentación correspondiente a la práctica médica realizada a fin de que se encuentre disponible cuando lo requieran los progenitores y/o el niño/a, cuando hubiera/n alcanzado la mayoría de edad o antes de ello si conforme a su edad o grado de madurez así correspondiera.

Con respecto a la situación de la gestante, de la prueba obrante en la causa, se puede advertir, que L. tuvo la capacidad suficiente para comprender cuál era y en qué consistía, el tratamiento al que se sometía, para lo cual no solo que tomó una decisión con el apoyo de todo su grupo familiar, sino que

presto la voluntad libremente de someterse en calidad de gestante para ayudar a otras parejas a obtener el deseo de ser padres. El primer indicio de ello, se advierte en la actitud de formar parte de un grupo de Facebook ofreciéndose para llevar adelante un embarazo (sin perjuicio de lo cuestionable que pueda ser la modalidad en que se conocieron y tomaron contacto, pues se requiere que el vínculo entre la pareja comitente y la gestante sea mayor, que sean conocidos para que el acompañamiento sea más natural). Esta modalidad de estar a disposición de quien lo requiera, determina a mi criterio que no fue seleccionada a petición exclusiva de la pareja comitente, pues quien primero manifiesta esa voluntad es L., lo que tiene trascendencia para descartar una posible vulneración, en la selección de la mujer gestante en este tipo de técnica. Por otro costado tengo en cuenta que conforme surge de la documental ofrecida y adjunta con fecha 05/12/2023, se presentó la copia de la valoración psicológica emitido por el Instituto Integral de Reproducción Asistida F. suscripto por la Lic. En psicología MP 9454 L. S. el que da cuenta que L. *denota condiciones psicológicas adecuadas para llevar adelante el proceso de sustitución y que con claridad ha entendido que no la unirá ningún vínculo con quien naciera del tratamiento médico de reproducción asistida de alta complejidad en el caso que se lograra concretar el embarazo.* Asimismo se incorporó en la misma fecha, copias del DNI de L. L. F. E. DNI xxx, hijo de L., copia de su DNI y del de su pareja Sra M. M. G. DNI xxx. Con fecha 13/12/2023 se adjunta el consentimiento previo, informado y libre- Número 3- llevado a cabo en el Instituto Integral de Reproducción Asistida F. para la fecundación in vitro (ICSI) - Gestación por sustitución con ovodonación (gestante solidaria), en el que no solo se informa acerca de la técnica de FIV/ICSI, se distingue las particularidades de la gestación por sustitución tanto en lo técnico, sus etapas, riesgos generales, resultados y estadísticas, dejando constancia que recibió la información obtenida por el equipo de profesionales que intervino en el tratamiento; así como los aspectos legales referida a las consecuencias y efectos jurídicos del procedimiento que se iba a llevar a cabo. Suscriptos por la Sra. L. y los comitentes S. - P. y por el Dr. P. A. J. A. MP xxx; todas las firmas se encuentran certificadas ante el Escribano Público Carlos Berberian. En cuanto a los cuidados físicos de L. se vislumbra del escrito inicial la realización solicitada por el Instituto de fertilidad de estudios tales como: 1. Hemograma y coagulograma 2. Perfil metabólico (glucemia, hepatograma con lipidograma) 3. Función renal (urea y creatinina) 4. Perfil hormonal (PRL, TSH, T4l, T3) 5. Grupo y factor 6. Hepatitis B s Ag (Antígeno de Superficie) 7. Hepatitis B core IgM 8. Hepatitis C anticuerpo 9. VDRL 10. VIH anticuerpo I y II 11. Toxoplasmosis 13. Chagas 14. Rubeola, examen físico ginecológico, ecografía ginecológica y mamaria, cultivo de flujo, urocultivo, citología cervical entre otros, valorados como resultados normales para llevar a cabo el tratamiento. Se acompaña

además el consentimiento previo (N° 3) suscripto por la misma, acerca de la valoración realizada por el equipo técnico del centro de salud Fundación F.

Incluso para garantizar la salud de L. los comitentes han contratado la locación de servicios de la Clínica y Maternidad del S. del servicio denominado "Maternidad Protegida- G.B", a favor Sra. L. L. para llevar a cabo la atención personalizada en el embarazo además del parto o cesárea, conforme el contrato adjunto con fecha 05/12/2023. Del informe elaborado por las profesionales del equipo técnico multidisciplinario de la Sede de Alta Gracia, llevado a cabo con fecha 08 de febrero de 2024 (adjunto al oficio librado con fecha 12/11/2023), se da cuenta, de su pleno, cabal y desinteresado apoyo a la realización de la gestación por sustitución. Ha quedado acreditado en autos que la voluntad de la gestante L. R. L. no se encuentra viciada, que tiene una verdadera noción de la acción que está emprendiendo, se han valorado sus condiciones de salud física y psíquica que le permitan llevar adelante el embarazo de manera adecuada para su propia integridad y la del por nacer; quien no llevará su aporte genético atento a que no ha aportado sus gametos, sino que lleva aporte genético del Sr. P.s con óvulos donados anónimamente. Asimismo, destacó que una vez obtenida la confirmación de que el embrión fuera fecundado; L. y su pareja habrían informado a los integrantes de su grupo familiar de convivencia sobre el acontecimiento; con la aclaración de que no desarrollarían vínculos, ni rol alguno en relación al niño/a que se halla en gestación.

La audiencia llevada a cabo con fecha 28/02/2024, en donde esta magistrada tuvo contacto personal y directo con las partes, la Sra. L. L. fue escuchada y relata cómo conoció a D. y S., ratifica que *su intención de gestar ha sido para darle la oportunidad a la pareja de ser padres, porque ella también tuvo esa necesidad y sabe lo que se siente.*

Expresó enfáticamente que la niña que lleva en su vientre, es de D. y S., que desde el principio a la fecha tiene muy claro que ella no iba a ser la mamá de la niña y no desea desempeñar un rol materno respecto de la niña, sino que ella fue instrumento para que los padres fueran D. y S. Agrega que ella tuvo y tiene el acompañamiento en esta decisión de su pareja e hijos. Durante toda la entrevista se advierte una persona de carácter y segura de las decisiones tomadas.

La gestante no ha recibido contraprestación alguna y las partes ponen en conocimiento que se le ha entregado dinero para los gastos propios de la práctica- siendo soportados por los comitentes. Se agrega que la gestante no se ha sometido a un proceso de este tipo anteriormente y que la misma posee dos hijos propios, L. de 13 años y L. de 8 años conforme surge del informe llevado a cabo por el Equipo técnico multidisciplinario de esta Sede que se condicen con sus propias manifestaciones. Con respecto a los comitentes, D. ha aportado su material genético y S. Maris se encuentra en imposibilidad física de llevar adelante un embarazo atento a tener diagnosticado síncope vasovagal cardio inhibidor y diabetes Tipo II, lo que fue acreditado con certificado médico suscripto por el Dr.

Benito Leopoldo Diaz Especialista en alergia e inmunología C.E 10181 adjunto con fecha 05/03/2024. Asimismo, debe verificarse que exista en ellos la voluntad procreacional en los términos del art. 562 del CCCN, entendida como ese "deseo de tener un hijo o hija sostenido por el amor filial que emerge de la constitución subjetiva de las personas" (Cfr: Gil Domínguez, Andrés: "La Voluntad Procreacional como derecho y orden simbólico", Ediar, Buenos Aires, 2014, p. 12), lo que así se ha corroborado a lo largo del caso de marras.

Ambos padres intencionales fueron sometidos a evaluación psicológica, con fecha 05/12/2023 se adjuntaron certificados psicológicos emitidos por el Instituto Integral de Reproducción Asistida F. suscripto por la Lic. en psicología MP 9454 L. Szrank llevado a cabo con fecha 07/12/2022 al Sr. D. P. y S.M.S., en donde se da cuenta que los comitentes denotan condiciones psicológicas adecuadas para llevar adelante el ICSI a realizarse con material genético del Sr. P. con donación de óvulos anónimos y subrogación de vientre a cargo de L. L.

Adjuntan los consentimientos previos, informados y libres suscripto por el Sr. D. E. P. en F. con fecha 16 de Junio de 2023 n° 22720576 y el consentimiento n° 22720576 suscripto por S.M.S. para el Tratamiento de reproducción humana asistida de Alta Complejidad con GAMETOS DONADOS - PAREJA, por el cual D. aporta su material genético para conformar el embrión y el ovocito será de donante anónimo. Asimismo, ambos han suscripto el consentimiento informado N° 1 y 2 para llevar a cabo el procedimiento de reproducción humana asistida de alta complejidad de Gestación por sustitución con ovodonación, y el consentimiento previo, informado y libre - Número 3- llevado a cabo en el Instituto Integral de Reproducción Asistida F. para la fecundación in vitro (ICSI) - Gestación por sustitución con ovodonación (gestante solidaria) cuyas firmas se encuentran certificadas por ante escribano público Carlos Barberían, y que se adjuntan con fecha 13/12/2023. Que del informe elaborado por las profesionales del equipo técnico multidisciplinario de este poder judicial (sede Alta Gracia) llevado a cabo con fecha 08 de febrero de 2024 (adjunto al oficio librado con fecha 12/11/2023) se da cuenta que al entablar relación el Sr. P., la Sra S. le habría expuesto su situación. Una vez avanzada la relación de pareja habrían proyectado ser padres, al mantener una vinculación estable durante 10 años. Habrían descartado la adopción al tomar conocimiento de la tardanza que dicho medio conllevaría, y habiéndose informado sobre la modalidad de subrogación de vientre, se habrían decidido a concretarla. Contando ambos con voluntad procreacional, habrían llegado a la opción de ser padres mediante la "Gestación por sustitución con una ovodonación, y material genético del Sr. P. Asimismo, recalco que, conforme surge del mismo informe que la familia más cercana de los padres intencionales, (padres y hermanos) conocerían de la voluntad procreacional, y que habrían recurrido al método de gestación por sustitución, y recibirían la contención de los mismos. Contarían con ofrecimientos de distintos miembros de la

familia extensa para ayudar y acompañar en la crianza de la niña, teniendo en consideración la salud de la Sra. S. Que en la audiencia del veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2024, en donde se toma contacto personal y directo con la magistrada, D. y S. M. relataron como se conocieron entre ellos y como se vincularon con L.. Manifestaron nuevamente sus deseos de ser padres y relatan que incluso la familia extensa está esperando que la niña nazca y sea parte de su familia, que todos están pendientes y comprometidos en su crianza y cuidados. Ratificaron en todos sus términos el pedido de autorización judicial formulado en el escrito de demanda, sostienen y reiteran su voluntad y deseo profundo de ser los padres de la niña por nacer, de formar junto a ella una familia, darle amor y protección, con un proyecto de vida en común; agregan que están sostenidos y acompañados por el resto de la familia extensa y se los nota muy emocionados.

Asimismo con fecha 05/12/2023 acompañan como documental libreta de familia donde consta su matrimonio celebrado con fecha el 12 de octubre del año 2013 y acreditan su solvencia económica adjuntando recibos de haberes del Sr. P. quien se encuentra trabajando en relación de dependencia en la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús Maria Ltda y el recibo de haberes con la percepción de la jubilación de la Sra. S.

CUARTO. Solución del caso. Conforme todo el análisis minuciosamente detallado supra, se dicta la presente resolución especialmente en miras al Interés Superior del niño/a por nacer; se encuentra reunidos los requisitos que se fijaron en el Anteproyecto del CCCN que son pautas básicas para determinar la procedencia de lo peticionado. Así se ha acreditado la existencia de la voluntad procreacional del Sr. D. E. P. y S. M.S.; se ha logrado acreditar que la gestante L. L. tiene plena capacidad y buena salud física y psíquica y que fue su libre voluntad la que la llevo a ofrecerse como gestante del niño/a de los comitentes; que se han prestados los respectivos consentimientos, previos, informados y libres de todas las partes intervinientes en este proceso de gestación por sustitución; que la Sra. S. M.S., tiene imposibilidad de concebir atento lo ha acreditado con la certificación medica de fecha 05/03/2024; la gestante no ha aportado sus gametos, por lo cual no la une un vínculo genético con el niño/a que lleva en su vientre; que sí ha aportado sus gametos el Sr. P.; que L. no ha recibido retribución que pueda transformar este procedimiento en una actividad comercial en violación a lo dispuesto por el Art 17 de CCCN); que este proceso de gestación por sustitución es el primero que realiza L. y que la gestante ha dado a luz dos hijos propios.

En consecuencia, respecto a la autorización peticionada, corresponde determinar que la filiación del niño/a que haya de nacer a consecuencia de la TRHA de sustitución por gestación, realizada en F. el 12 de julio de 2023 de transferencia embrionaria en la Sra. L. R. L. DNI xxx.489 será hijo/a de la Sra. S. M.S. DNI xxx y D. E. P. DNI xxx, e inscribir en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a la persona humana, nacida con vida como consecuencia del procedimiento llevado a

cabo y del embarazo llevado adelante por la Sra. L. R. L. como hija de los Sres. D. E. P. y S. M.S., en los términos del Art. 559 del CCCN, puesto que no existe vínculo biológico del niño/a por nacer con la Sra. L. R. L., ni existe en ésta última voluntad procreacional, siendo en cambio su voluntad sólo la de llevar adelante el embarazo del niño por nacer con una finalidad de solidaridad para que la Sra. S. M.S. y D. E. P. formen su familia. Asimismo se dispone que la pareja comitente son los únicos autorizados para tomar cualquier tipo de decisión sobre el nacido/a (consentimientos médicos, retiro -una vez producida el alta médica- del establecimiento donde haya de tener lugar el nacimiento, etc.) toda vez que ello se enmarca en el ejercicio de los derechos que titularizan como progenitores.

QUINTO: Inconstitucionalidad del Art 562 del CCCN Los peticionantes en su escrito inicial plantean la inconstitucionalidad o inaplicabilidad del Art. 562 del CCCN. En primer lugar, corresponde resaltar que el control de constitucionalidad se basa en que las leyes deben interpretarse considerando en forma armónica la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional. Asimismo, nuestro sistema de control difuso permite que cualquier Juez analice la constitucionalidad de una norma de rango inferior. Se trata de una delicada tarea que pesa sobre los integrantes del Poder Judicial, y más allá de que se encuentre habilitado o no el pronunciamiento oficioso sobre tal declaración, sigue importando la última *ratio* de la función de la judicatura, al constituir un acto de extrema gravedad institucional (conf.: CSJN, Cfr. Fallos: 316:2624, 319:3148, 323:2409), habida cuenta de la presunción de legitimidad de la cual gozan las leyes debidamente sancionadas y promulgadas (conf. CSJN, Fallos: 319:1524), que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Conf. TSJ, "Giansetto Renato Livio Augusto c/ Municipalidad de Córdoba - Ejecutivo - Expte. N° 225174/36 - Recurso de Casación e Inconstitucionalidad"). Es por ello que indiscutiblemente la declaración judicial de inconstitucionalidad de una norma, por su gravedad, es de interpretación restrictiva.

Por eso, su razonabilidad es un principio cardinal para su validez. Este principio se encuentra consagrado por nuestra Carta Magna en su art. 28, el que textualmente dispone: *"Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio"*. La razonabilidad exige que el medio escogido para alcanzar un fin válido guarde relación proporción y aptitud suficientes con ese fin. Según señala Bidart Campos, no es fácil dilucidarla en cada situación pero entiende que este concepto jurídico indeterminado se esclarece cuando se penetra el núcleo esencial de cada derecho. Tal núcleo es el que no tolera supresión o, en otros términos, es ese núcleo el que no puede extinguirse, alterarse, dañarse o

frustrarse. Cuando el núcleo queda preservado, toda otra limitación al derecho es razonable. Cuando el núcleo se afecta de la manera dicha, hay arbitrariedad e inconstitucionalidad..." (cfr. Bidart Campos, *Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino*, t. I, Ed. Ediar, pp. 361 y ss.). El artículo cuestionado, reza: "*Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida, SON HIJOS DE QUIEN DIO A LUZ y del hombre o mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los Arts. 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quien haya aportado los gametos*". Claramente la situación contemplada por la norma se aplica cuando la misma mujer que está realizando la THRA gesta su propio bebe y lo da a luz, pero no se condice para los supuestos de sustitución de vientre. Es que, la carencia legislativa, los avances científicos, la imposibilidad de contemplar en su totalidad los cuantiosos TRHA y sus diversas consecuencias que permitan resguardar todos los derechos, de todas las personas que intervienen en ellos, por su simple condición de personas (DDHH) y atendiendo especialmente los desequilibrios que se pudieren plantear en cada caso concreto, hacen utópica la subsunción directa del caso a un determinado artículo, debiendo acudir para dar una solución jurídica, a las normas existentes, convenciones internacionales y principios del derecho.

Lo que sucede, es que el sistema que ha optado el CCCN, fue aceptar a las TRHA como una fuente de filiación, filiación que tiene su base o se determina en la voluntad procreacional. Ahora bien, la diversidad de técnicas y la casuística inabarcable de situaciones fácticas y jurídicas que ello genera, presentan supuestos que quedan en pugna con ciertas normativas como la del Art. 562 del CCCN que claramente no ha contemplado la situación de la gestación por sustitución en donde ostensiblemente QUIEN DA A LUZ, **NO TIENE VOLUNTAD PROCREACIONAL Y NO TIENE VÍNCULO GENÉTICO CON EL NIÑO QUE LLEVA EN SU VIENTRE**. Ello violenta el interés superior del niño gestado (Art. 3.1 de la CDN; Art. 3 de la ley 26.061), de la voluntad propia de una mujer quien no tiene deseos de maternar (a la que incluso corresponde aplicar perspectiva de género poniendo énfasis y respetando su decisión), y los de la pareja comitente, violando claramente derechos convencionales y principios como los de no discriminación (conf. art 17 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art 16 Declaración Universal de Derechos Humanos), de igualdad (art 16 Constitución Nacional, art 24 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art 2 Declaración Universal de Derechos Humanos y art 3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y de tutela judicial efectiva (artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art 2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Debo resaltar por sobre cualquier otra situación, que L. tiene un embarazo avanzado, que no estamos dando una autorización para realizar el TRHA, sino que ya existe un niño/a a punto de

nacer, con lo cual desplazo los derechos de otros sujetos para un análisis secundario, como así también priorizo el interés de este sujeto por nacer, por encima de toda norma sustancial, procesal o principio legal existente, conforme lo ordena la Observación N° 14 del Comité de los Derechos del Niño y en clara aplicación de lo que me obliga el Art. 8 de la CDN y Obs Gral 5 del Comité de los Derechos del Niño.

Permitir la aplicación del Art. 562 del CCCN, es decir, que esta persona por nacer, sea considerado hijo/a de L., entorpecería al bienestar y desarrollo del sujeto protegido, sometiéndolo a una inseguridad jurídica, a una burocracia innecesaria y no querida por ninguna parte de quienes han intervenido en este tratamiento. Este niño/a ha sido querido, buscado y esperado por una familia que ha acudido a cuanto estuvo a su alcance y siguiendo todos los pasos legales para poder recibirlo como progenitores. Inscribirlo como hijo/a de L. sería negarle la posibilidad que desde su origen tenga la documentación que refleje su identidad familiar y la realidad de su historia en condiciones materiales y afectivas óptimas, por lo que considero que la declaración de inconstitucionalidad del Art. 562 del CCCN, sería lo más beneficioso para el niño/a por nacer. Sumo a todos estos argumentos, los expuestos por la Asesora letrada Dra. Assadourian en la vista corrida, quien atiende la protección en el niño/a por nacer (CDN, Ley 26.061, Protocolo de Actuación de la Oficina de DDHH del TSJ, Convención Americana sobre los DDHH, etc), como los del representante del Ministerio Público Fiscal (Art. 7.1 de la CDN, doctrina y jurisprudencia).

En cuanto a L. ha expresado constantemente y ha mantenido la decisión de no maternar desde su origen. Desde una perspectiva de género, debo atender su voluntad que ha sido ampliamente libre y altruista, que sus actos han sido producto de su autonomía personal, que solicitó incluso en la audiencia que el niño sea de la pareja comitente en resguardo de su propia vida privada y familiar y en un todo de acuerdo como se había estipulado con D. y S. M. Sería una desprotección total a L. considerar la aplicación del Art. 562 del CCCN. En relación a la pareja comitente, no sólo se verían violados sus derechos de no discriminación, de igualdad, de realidad, de tutela judicial efectiva, autonomía personal, derecho a fundar una familia, a procrear mediante la voluntad procreacional, a gozar de los beneficios del progreso científico, sino que emocionalmente lesionaría parte de sus expectativas y además hacerlos peregrinar por más trámites legales y administrativos para cumplir con el sueño de conformar una familia con ese bebe que ya llega. Si se analiza el artículo en cuestión, se advierte que no se ajustaría a esta realidad, es que el niño/a por nacer, no debe ser considerado hijo/a de quien dará a luz, sino hijo de QUIENES HAN PRESTADO SU CONSENTIMIENTO PREVIO, INFORMADO Y LIBRE, pues en los supuestos de gestación por subrogación, la intervención de la gestante culmina o se agota con el nacimiento del niño/a. A los efectos de la presente resolución, la filiación, la paternidad/maternidad y su correspondiente

inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas resulta trascendente para el derecho la voluntad procreacional (y en el caso del Sr. P. también su aporte genético), y no la donación de gametos o la gestación en otro vientre. Así se ha expresado que la voluntad procreacional es el elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando la misma ha sido producto de una TRHA, es lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia nacional, aún antes de la entrada en vigencia del CCCN, cuando sostuvieron que: "el querer engendrar un hijo, darle afecto y asumir la responsabilidad de su educación y crianza, por ello contiene sin dudas el elemento volitivo que tiene en miras adquirir derechos y obligaciones emergentes de la relación paterno filial que, justamente, en el campo de la reproducción humana asistida es la típica fuente de creación del vínculo" (Fallo del 18 de junio de 2013 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 86, dictado en autos "N.N. o DGMB s/Inscripción de nacimiento). En base a todo lo expuesto y en un todo de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Instrucción de competencia múltiple del Primer Turno, en su carácter de representante del Ministerio Público Fiscal, entiendo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 562 del CCCN, en cuanto dice que *"Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida, SON HIJOS DE QUIEN DIO A LUZ"*.

Consecuentemente reitero, corresponde que en toda la documentación vinculada a la identidad del niño/a, desde el mismo instante de su nacimiento, se consignen como progenitores (madre/padre) a la Sra. S.M.S. DNI xxx y D. E. P. DNI xxx, debiendo inscribirse en el Registro de Estado Civil y de Capacidad de las Personas en tal sentido y de conformidad a lo normado por el 559 del CCCN.

SEXTO. Acción Preventiva: La regla axiológica que consagra el deber general de no dañar, derivada del principio romanista del "alterum nom laedere", supone obviamente, "reparar el daño causado" pero sobre todo **"no causar daños"**, es decir, evitar que se produzcan (LLAMAS POMBO, Eugenio, "La tutela inhibitoria del daño" (la otra manifestación del derecho de daños" en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Buenos aires, Ed. La Ley 2002, pág. 181.)

En esta sociedad en la que los derechos más valiosos han sufrido un menoscabo importante - principalmente los de contenido no patrimonial o prevalentemente no patrimonial, era necesario la creación de una herramienta que posibilite prevenir el ilícito, evitar su repetición e impedir que sus efectos se propaguen (IGLESIAS, Laura, "La Tutela Judicial Inhibitoria", Libro de Ponencias del Congreso de Derecho Procesal, año 2009, BERIZONCE, R.O. "Tutelas procesales diferenciadas", Rubinza-Culzoni, 2009.) En el derecho civil se consideraba que la intervención jurisdiccional solo se justificaba cuando ya se había ocasionado el daño y a los fines de su reparación. Afortunadamente se ha avanzado en esa concepción y actualmente se abre camino a la función preventiva del daño como atributo de la actividad de la magistratura. A través de la función

jurisdiccional el Estado debe dar certeza a los conflictos o situaciones de incertidumbre o inseguridad que se producen en la sociedad, debe buscar prevenir en lugar de reparar, dejando de lado el pensamiento clásico de la sentencia de condena que sirve solo para solucionar lo ya dañado - hacia atrás- y no para evitar un daño -hacia adelante- (MORELLO, Augusto M. y STIGLITZ, Rubén A. "Tutela Procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos", La Plata , Platense 1986, pág.4). Desde otro aspecto, la jurisdicción preventiva se ha ido generando a lo largo de los años siendo acogida por la doctrina y por los tribunales con motivo de los reiterados reclamos a aquellos que procuraban ser amparados por el órgano judicial. Así, la argumentación del pedido debía fundarse en el art. 43 de la Constitución Nacional y en el principio de tutela judicial efectiva establecido en el art. 8.2 de la CHDH. El derecho positivo consagró la función preventiva y jurisdiccional mediante la directiva general del art. 1067 del Código Civil. De él emerge responsabilidad no solo por el daño causado (perspectiva del resarcimiento) sino también por el que se puede causar (prevención) facultándose a los jueces a ordenar la cesación de daños anexos a una conducta o actividad -al margen de otras consecuencias jurídicas eventuales: resarcimiento, publicación de la sentencia. También se hizo presente la función preventiva mediante el dictado de diferentes normas sustanciales, obligación de cesar en actividades lesivas de la intimidad ajena (art. 1071 del Cód. Civil), daño temido (art. 2499, del Cód. Civil), inmisiones entre fundos vecinos (2618 del cód. Civil), vía de acción confesoria y denegatoria (arts. 2795/2799 y 2800/804), propiedad intelectual, propiedad horizontal (ley 13.512), competencia desleal (ley 22.262), en materia de los derechos de los consumidores o usuarios (arts. 53 y 54, ley 24240), entre otros. (Barrera Mónica. www.infojus.gov.ar. Id SAIJ: DACF150372. 16/07/2015). **Hoy esta función se encuentra receptada en el Código Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 1711 a 1715, aplicable a un amplio ámbito. Constituye una protección judicial de urgencia sustantiva. La acción preventiva puede tratarse de una medida accesorio. El objeto es impedir la producción o agravamiento del daño y serán de las más variadas de acuerdo a las circunstancias.** Consistirán en detener o frenar un hecho, hacer cesar la realización de una actividad, asegurar o modificar una situación de hecho o de derecho, imponer obligaciones de hacer o no hacer o de dar. Y puede ser introducida de oficio conforme el Art. 1713 del CCCN, obviamente siempre que sea en el marco de un proceso iniciado o en curso. En este marco y con las facultades que me otorga la ley, estimo apropiada la procedencia de esta acción preventiva en el presente proceso. Doy razones. La mentada alegación en la técnica de sustitución de vientre o gestación por sustitución, si bien ha logrado autorizaciones judiciales invocando principalmente el Art. 19 de la CN, es de suyo que no necesariamente conlleva la permisión de hacer, realizar o no, todo lo que no esté prohibido, sin que ello tenga consecuencias legales. Hay innumerables conductas y situaciones que no pueden estar

contempladas en una normativa y no por ello necesariamente son aceptadas por los resultados que pueden acarrear.

En el caso de autos, mención especial merece la conducta del centro de salud F.. Claramente, teniendo conocimiento que el Poder Judicial, utiliza como herramienta o guía las Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida (art 562 "*Gestación por sustitución*") del Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial, los procedimientos que llevan a cabo en dicho instituto, procuran respetar todos los incisos descriptos en él. Así por ejemplo vemos que en el caso de autos, se sometieron a las partes a una valoración de salud física y psíquica, constataron la imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término, que la gestante no aporte sus gametos, que ésta no reciba retribución, que no haya sido esa gestante sometida a este tipo de proceso más de dos veces, que la gestante haya dado a luz al menos un hijo propio, además se encargó de que las partes presten los consentimientos previos, informados y libres y prestan a modo de contrato de adhesión la documentación necesaria para llevar a cabo la práctica. Sin embargo se aparta del anteproyecto guía en cuanto reza "LOS CENTROS DE SALUD NO PUEDEN PROCEDER A LA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA EN LA GESTANTE, SIN LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA"

Ahora bien, la falta de reglamentación específica, justifica el proceder poco cauto y dañino de traer un niño a este mundo con el riesgo de no obtener dicha autorización? En qué situación legal queda ese niño? Porqué hacerlo transitar por un camino tan cruel pudiendo evitarse tal circunstancia con requerir una autorización judicial previa a la transferencia embrionaria? Porque habría que imponerle la maternidad a una mujer que no quiere ser madre y solo quiso ayudar a otras personas? Con qué necesidad los progenitores con voluntad procreacional se verían lesionados en su proyecto familiar al estar esa posibilidad de la no autorización? En el caso de autos, se reunieron los requisitos y quedó desplazada todo tipo de vulnerabilidad de la gestante, que es mayormente lo que un juez debe resguardar en estas tratativas, dejando a salvo que lo expresado en este acápite, no se refiere a este caso puntual. Pero que hubiera pasado si se hubiese advertido un desequilibrio entre la gestante y los comitentes? Es que realmente el centro de salud, en esos supuestos lo pasa por alto? Tiene un actuar desaprensivo? Un actuar negligente? Se limita a lo meramente comercial? En realidad, no está fabricando un mueble o un producto, **es una vida la que está trayendo a este mundo!!!**. Un ser vivo que tiene condición de persona y que tiene todos los derechos que le asisten como tal y con una protección especial por su condición de vulnerabilidad a saber: El individuo como ser único e irrepetible, posee el derecho personalísimo a la identidad que como tal es el elemento más importante de construcción de su personalidad, esto significa, en primer lugar **la identificación por el Estado, mediante los documentos, pertinentes a tal fin y la pertenencia a**

una determinada familia. El art. 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que:

"1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos". Asimismo, el art. 8 estipula que: "1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. **2. Cuando un niño sea**

privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad." El interés superior del niño se asegura con un marco legal de protección, que "brinde seguridad jurídica y le garantice una filiación acorde a la realidad volitiva" (Tratado de Derecho de Familia según el CCCN de 2014, dirigido por Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora: Tomo II, art. 590 a 593, 1ª edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pág. 526).

Una vez más y sin pecar de ser reiterativa, el interés superior del niño, como lo estableció el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General Nro. 5 (2003), es un principio rector que todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y judiciales han de aplicar en todas las medidas que adopten, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero los afectan (párr.13). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 17/2002 sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, expresó que el interés superior del niño ha de ser entendido "como la premisa bajo la cual debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia (...) se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño (...) y es el punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en este instrumento, cuya observación permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades".

Por lo que entiendo, que es obligación de la suscripta evitar este tipo de perjuicio, procurando hacer saber a los centros de salud, que NO DEBEN PROCEDER A LA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SIN LA AUTORIZACION JUDICIAL PREVIA.

Pues es TAN ENORME EL DAÑO QUE PUEDE GENERAR EN UN NIÑO POR NACER, QUE NO PODRÍA SIMPLEMENTE EXONERARSE EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON UNA CLAUSULA CONTRACTUAL, pues la manipulación de todo este proceso, solamente se encuentra en sus manos y puede evitar gravísimos daños. Es por ello que exhorto a F. y todos los institutos o centros de salud que lleven adelante este tipo de prácticas a informar, aconsejar y acompañar a las personas que se sometan a LA GESTACIÓN POR SUSTITUCION a obtener la

correspondiente autorización judicial de manera PREVIA a la transferencia del embrión al cuerpo de la mujer gestante, NO PROCEDIENDO A TAL TRANSFERENCIA HASTA TANTO NO EXISTA AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Asimismo exhorto a F. a readecuar el modelo de consentimiento informado en donde dice "en dicho proceso se requerirá judicialmente autorización para la gestación sustitutiva, con carácter previo al nacimiento del niño/a una vez embarazada la gestante" (ver pag 7 tercer párrafo del consentimiento n° 3).

Asimismo me sumo a la exhortación dirigida al Poder Legislativo efectuada por la Sra. Jueza de Primera Instancia y Primera Nominación de Familia, de la Ciudad de Córdoba, Dra. M. Belén Mignon quien en los autos caratulados "W.,B.- C.,L.E. - R.T., D.S. - Solicita homologación - Ley 10.305" en la resolución N° 386 de fecha 07/06/2023 dispuso: **2) Exhortar al Poder Legislativo a fin de que regule dicha técnica de alta complejidad tendiente a lograr la superación de la dificultades que el vacío legal provoca, siendo endeble los criterios de determinadas praxis sociales que en post de salvaguardar los intereses de las personas más vulnerables.**

SEPTIMO. Costas: Sin costas atento la naturaleza de lo peticionado. Por todo lo expuesto,

RESUELVO:1) Determinar que la filiación del niño/a que haya de nacer a consecuencia de la TRHA de sustitución por gestación, realizada en F. el 12 de julio de 2023 de transferencia embrionaria en la Sra. L. R. L. DNI xxx será hijo/a de la Sra. S. M.S. DNI xxx y D. E. P. DNI xxx, debiendo los progenitores informarle/s, oportunamente y con ajuste a su edad y grado de madurez, su origen gestacional y debiendo el Instituto F., mantener reservada toda la documentación correspondiente a la práctica médica realizada a fin de que se encuentre disponible cuando lo requieran los progenitores y/o el niño/a, cuando hubiera/n alcanzado la mayoría de edad o antes de ello si conforme a su edad o grado de madurez así correspondiera.

2) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 562 del CCCN, en este caso concreto de gestación por sustitución, de conformidad a lo expuesto en el considerando respectivo.

3) Consecuentemente corresponde que en toda la documentación vinculada a la identidad del niño/a, desde el mismo instante de su nacimiento, se consignen como progenitores (madre/padre) a la Sra. S.M.S. DNI xxx y D.E.P. DNI xxx. Procédase a la inscripción en el Registro de Estado Civil y de Capacidad de las Personas en tal sentido y de conformidad a lo normado por el 559 del CCCN.

4) Poner en conocimiento que los únicos autorizados al retiro del niño/a del hospital/sanatorio, luego de su nacimiento - y alta médica mediante- serán sus progenitores, Sres. S. M.S. DNI xxx y D.E.P. DNI xxx.

5) Sin costas atento la naturaleza de la pretensión. **6)** Exhortar al Instituto Integral de Reproducción Asistida F. para que en las TRHA, de GESTACIÓN POR SUSTITUCION requiera la correspondiente autorización judicial de manera PREVIA a la transferencia del embrión al cuerpo de la mujer gestante, NO PROCEDIENDO A TAL TRANSFERENCIA HASTA TANTO

NO EXISTA AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Asimismo, exhorto al establecimiento a readecuar el modelo de consentimiento informado en ese mismo sentido. 7) Exhortar al Poder Legislativo a regular legalmente la TRHA de gestación por sustitución de alta complejidad tendiente a lograr la superación de las dificultades que el vacío legal provoca, siendo endeble los criterios de determinadas praxis sociales que en post de salvaguardar los intereses de las personas más vulnerables. **Protocolícese, hágase saber y dese copia.**

Texto Firmado digitalmente por:

CALDERON Lorena Beatriz

JUEZ/A DE 1 RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.03.14